

<제9장 무효등 확인소송.제5절 취소소송과의 관계>

I. 문제점

- 취소소송과 무효등 확인소송은 모두 행정청의 처분등의 위법성을 다투는 항고소송이라는 공통점을 가진다. 그러나 취소소송은 취소 사유(하자가 있거나 공정력 인정)를, 무효등 확인소송은 무효 사유(중대하고 명백한 하자, 공정력 불인정)를 대상으로 한다. 이 차이로 인해 다음과 같은 문제들이 발생한다. 첫째, 두 청구를 하나의 소송에서 병합할 수 있는지 여부, 둘째, 처분의 하자 정도를 잘못 판단하여 무효 사유가 있는 처분에 대해 취소소송을 제기하거나, 반대로 취소 사유가 있는 처분에 대해 무효등 확인소송을 제기했을 때 법원이 어떻게 판단해야 하는지 여부 등이 주요 쟁점이다.

II. 취소소송과 무효등 확인소송의 병합

1. 주위적·예비적 청구로만 병합 가능

- 취소소송의 제소기간은 엄격한 제한이 있는 반면, 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없다. 따라서 두 청구를 단순히 합치는 단순 병합을 허용할 경우, 제소기간 제한이 없는 무효등 확인소송을 이용하여 사실상 취소소송의 제소기간을 잠탈하는 결과가 발생할 수 있다. 이에 판례는 두 청구를 주위적 청구와 예비적 청구로만 병합하는 것을 허용한다.

2. 병합형태

(1) 무효등 확인청구를 주위적으로 제기한 경우

- 원고가 무효등 확인청구를 주위적으로 하고, 취소청구를 예비적으로 병합하는 형태이다. 이는 처분의 하자가 무효 사유에 해당한다고 강하게 주장하면서도, 법원이 이를 취소 사유로 판단할 경우에 대비하는 방식이다. 법원은 주위적 청구인 무효등 확인청구에 대해 먼저 심리하고, 이를 기각할 경우에만 예비적 청구인 취소청구를 심리한다. 이 경우 예비적 청구인 취소소송은 제소기간 요건을 충족해야만 본안 심리가 가능하다.

(2) 취소청구를 주위적으로 제기한 경우

- 원고가 취소청구를 주위적으로 하고, 무효등 확인청구를 예비적으로 병합하는 형태이다. 이는 처분의 하자가 취소 사유에 해당한다고 주장하면서도, 법원이 이를 무효 사유로 판단할 경우에 대비하는 방식이다. 법원은 주위적 청구인 취소청구를 먼저 심리하며, 주위적 청구가 기각될 때 예비적 청구인 무효등 확인청구를 심리한다.

III. 무효사유가 있는 처분에 대하여 취소소송을 제기한 경우

- 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 무효 사유에 해당함에도 불구하고, 원고가 착오로 취소소송을 제기한 경우이다.

1. 문제점

- 무효인 처분은 공정력이 없으므로 취소소송의 대상이 될 수 없다는 견해도 존재하지만, 판례는 취소소송의 대상인 처분의 개념을 넓게 해석하여 무효인 처분도 포함될 수 있는지 여부에 대해 다름이 있었다.

2. 판례의 태도

- 판례는 무효 사유가 있는 처분이라도 이를 취소소송의 대상인 처분에 포함된다고 본다. 따라서 법원은 취소소송의 형태로 제기된 소를 적법한 것으로 보아 본안 심리를 진행한다. 다만, 심리 결과 처분이 무효 사유에 해당한다고 판단될 경우, 법원은 취소 판결을 내리는 것이 아니라 무효확인 판결을 내리거나 당원 무효임을 전제로 취소 판결을 내리게 된다. 이는 무효등 확인소송의 판결이 취소소송 판결의 효력 규정을 준용하는 점, 그리고 취소소송의 제소기간 내에 소가 제기되었으므로 원고에게 최대한의 권리 구제 기회를 제공해야 한다는 소송 경제적 관점에서 비롯된 해석이다.

IV. 취소사유가 있는 처분에 대하여 무효등 확인소송을 제기한 경우

- 처분에 취소 사유에 해당하는 위법한 하자가 있음에도 불구하고, 원고가 착오로 무효등 확인소송을 제기한 경우이다.

1. 문제점

- 무효등 확인소송은 무효 사유에 해당하는 처분만을 대상으로 하므로, 법원이 심리 결과 처분의 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단했을 때, 원고의 청구 형태를 그대로 유지하여 기각해야 하는지, 아니면 청구의 변경 등을 통해 취소소송으로 구제해 주어야 하는지가 문제된다.

2. 견해의 대립

(1) 청구 기각설

- 청구 기각설은 무효등 확인소송은 중대하고 명백한 하자를 전제로 하므로, 법원이 심리 결과 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단되면, 원고의 무효 확인 청구는 이유가 없는 것으로 보아 기각 판결을 내려야 한다는 견해이다. 판례는 무효등 확인소송의 심리 결과 취소 사유에 해당하는 하자가 발견된 경우에도 청구를 기각하고, 원고에게 소를 변경하거나 별도로 취소소송을 제기할 것을 요구해야 한다고 본다. 이는 취소소송의 제소기간 제한이라는 엄격한 요건을 무효등 확인소송을 통해 잠탈하는 것을 방지하고, 두 소송의 구별 실익을 유지하려는 취지이다.

(2) 취소소송으로의 전환 허용설 (소 변경 허용)

- 소 변경 허용설은 법원이 직권으로 청구를 취소소송으로 변경할 수 있도록 하거나, 석명권을 행사하여 원고에게 소의 변경을 유도해야 한다는 견해이다. 이는 원고에게 최대한의 권리 구제를 제공해야 한다는 실질적 정의 관념과 소송 경제의 측면을 강조한다. 그러나 이 견해는 취소소송의 제소기간 요건을 무력화시킬 우려가 있다.

(3) 최근 판례

- 과거 판례가 소송 형식에 구애받지 않는 폭넓은 취소판결의 가능성을 열었다면, 최근 판례는 이를 정교화하여 취소소송의 요건을 갖춘 경우라는 제한적 범주 내에서 무효 선언적 의미의 취소판결을 인정하고 있다.

V. 결론

- 취소소송과 무효등 확인소송은 하자의 정도에 따라 구별되지만, 소송상 청구의 병합은 주위적·예비적 병합 형태로만 허용된다. 무효 사유가 있는 처분에 대한 취소소송은 판례가 이를 허용하여 인용 판결을 내릴 수 있도록 하며, 취소 사유가 있는 처분에 대한 무효등 확인소송은 취소소송의 요건을 갖춘 경우라면 무효선언적 의미의 취소판결을 인정한다.

<보충-무효사유와 취소사유의 비교>

I. 행정행위의 하자과 효력의 관계

- 행정행위가 적법하게 성립하기 위해서는 주체, 내용, 절차, 형식의 요건을 모두 갖추어야 한다. 이러한 요건 중 일부를 결여한 경우를 행정행위의 하자라고 하며, 하자의 정도에 따라 당해 행정행위는 무효가 되거나 취소가 가능한 상태가 된다. 무효와 취소의 구별은 행정법 관계의 안정성과 국민의 권리구제라는 두 가지 측면에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 이하에서는 무효사유와 취소사유의 정의, 구별 기준, 그리고 구체적인 효력상의 차이점에 대하여 논한다.

II. 무효사유와 취소사유의 개념

1. 무효사유의 정의

- 행정행위의 하자가 중대하고 명백하여 외관상 행정행위로서 존재함에도 불구하고 처음부터 아무런 효력도 발생하지 않는 경우를 의미한다. 무효인 행정행위는 누구의 주장이나 법원의 판결을 기다릴 필요 없이 당연히 효력이 없는 것으로 간주된다.

2. 취소사유의 정의

- 행정행위에 하자가 있으나 그 하자가 무효가 될 정도로 중대하고 명백하지는 않아, 권한 있는 기관(행정청 또는 법원)에 의해 취소되기 전까지는 유효한 것으로 통용되는 상태를 의미한다. 이는 행정행위의 공정력에 근거한 것으로, 취소권자가 취소권을 행사하면 처분 시로 소급하여 효력을 상실하게 된다.

III. 무효와 취소의 구별 기준

1. 중대·명백설 (다수설 및 판례)

- 행정행위의 하자가 중대하고도 명백한 경우에만 무효로 보아야 한다는 견해이다. 여기서 중대성이란 하자가 행정행위의 중요한 요건을 위반한 것을 의미하며, 명백성이란 하자의 존재가 외관상 누구나 알 수 있을 정도로 분명한 것을 의미한다.

2. 구별의 구체적 판단

- 판례는 하자가 중대하더라도 명백하지 않은 경우에는 취소사유에 불과하다고 판단한다. 이는 행정처분의 유효성을 믿은 제3자의 신뢰를 보호하고 법적 안정성을 유지하기 위함이다. 반면, 하자가 중대하고 명백하여 행정의 일관성을 희생하더라도 그 효력을 부정해야 할 객관적 사정이 있는 경우에는 무효로 파악한다.

IV. 무효와 취소의 효력상 차이점

1. 공정력과 강제력의 인정 여부

- 취소사유가 있는 행정행위는 취소되기 전까지 유효한 것으로 추정되는 공정력을 가진다. 따라서 국민은 그 효력을 부인할 수 없으며 행정청은 이를 근거로 강제집행을 할 수 있다. 반면, 무효인 행정행위는 공정력이 발생하지 않으므로 처음부터 강제력을 행사할 수 없으며, 국민은 이에 따를 의무가 없다.

2. 제소기간의 제한 여부

- 취소소송은 행정소송법상 처분등이 있음을 안 날부터 90일, 있는 날부터 1년이라는 엄격한 제소기간의 제한을 받는다. 그러나 무효등 확인소송은 그 효력이 처음부터 없는 것이므로 시간의 경과에 관계없이 언제든지 제기할 수 있어 제소기간의 제한을 받지 않는다.

3. 행정쟁송의 형태

- 취소사유인 경우에는 취소소송 또는 취소심판을 제기하여야 하나, 무효사유인 경우에는 무효등 확인소송 또는 무효등 확인심판을 제기한다. 다만, 판례는 무효사유인 경우에도 취소소송의 형식으로 다투는 것을 허용하고 있다(무효를 선언하는 의미의 취소판결).

4. 하자의 치유와 전환

- 취소할 수 있는 행정행위는 일정한 요건 하에 하자의 치유(사후적인 요건 보충 등)가 인정될 수 있으나, 무효인 행정행위는 하자의 치유가 인정되지 않는다. 다만, 무효인 행정행위가 다른 행정행위의 요건을 갖춘 경우 다른 행위로 효력을 발생시키는 무효행위의 전환은 논의될 수 있다.

5. 선결문제로서의 효력

- 민사소송이나 형사소송에서 행정행위의 효력이 선결문제가 된 경우, 취소사유인 행정행위는 법원이 스스로 효력을 부인할 수 없으므로 행정소송을 통해 취소되지 않는 한 유효한 것으로 재판의 전제를 삼아야 한다. 그러나 무효인 행정행위는 민·형사법원이 독자적으로 그 효력이 없음을 전제로 판결할 수 있다.

V. 관련 판례를 통한 검토

1. 조세채무 확정 후 법률의 위헌 결정

- 판례는 법률에 근거하여 조세 부과 처분이 내려진 후 그 근거 법률이 위헌으로 결정된 경우, 당해 처분의 하자는 중대하지만 명백하다고 할 수 없으므로 원칙적으로 취소사유에 해당한다고 본다. 법률이 위헌 결정되기 전까지는 법규의 효력이 유효한 것으로 믿는 것이 일반적이기 때문이다.

2. 권한 없는 기관의 행정처분

- 권한 없는 기관의 행한 처분은 주체에 관한 중대한 하자가 있으므로 원칙적으로 무효라는 것이 사법부의 입장이다. 다만, 권한의 위임 등이 존재하여 외관상 권한이 있는 것처럼 보이고 그 유무를 가리는 데 정밀한 조사가 필요한 경우에는 명백성 요건이 결여되어 취소사유로 분류되기도 한다.

3. 절차적 하자의 정도

- 청문 절차를 거치지 않거나 이유 제시를 누락한 것과 같은 절차적 하자는 대개 취소사유로 다루어진다. 다만, 법령에서 정한 필수적 절차를 완전히 무시하여 처분의 정당성을 본질적으로 훼손한 수준에 이르면 무효로 판단될 여지가 있다.

VI. 결론

- 무효사유와 취소사유의 구분은 법적 안정성과 구체적 타당성 사이의 조화를 도모하기 위한 법적 장치이다. 취소사유는 행정행위의 공정력을 인정하여 일단 행정의 원활한 집행을 보장하되 사후적인 교정 기회를 부여하는 것이며, 무효사유는 중대한 오류가 있는 행정권 행사에 대하여 처음부터 법적 구속력을 박탈하는 것이다. 실무적으로는 제소기간의 도과 여부나 사법심사의 범위가 달라지므로, 하자의 정도를 객관적인 기준에 따라 엄격히 판단하는 태도가 요구된다. 국민의 권리 구제 측면에서는 무효를 폭넓게 인정하는 것이 유리할 수 있으나, 행정법 관계의 조속한 확정을 위해서는 중대·명백설의 취지를 존중하며 사안별로 신중한 접근이 필요하다.

<보충-주위적 청구와 예비적 청구의 비교>

I. 소송상의 복수청구와 병합의 의미

- 민사소송이나 행정소송에서 원고는 하나의 소송절차를 통해 여러 개의 청구를 동시에 제기할 수 있다. 이를 청구의 병합이라 하며, 분쟁을 일거에 해결하여 소송경제를 도모하고 판결의 모순과 저촉을 방지하는 데 목적이 있다. 병합의 형태 중 주위적 청구와 예비적 청구는 청구 간에 순위를 두어 심판을 구하는 독특한 구조를 가진다. 이하에서는 주위적 청구와 예비적 청구의 정의, 성립 요건, 심리 방식 및 판결의 효력에 대하여 구체적으로 논한다.

II. 주위적 청구와 예비적 청구의 개념

I. 주위적 청구의 정의

- 주위적 청구란 원고가 소송을 통해 제1차적으로 심판을 구하는 청구를 의미한다. 원고가 가장 우선적으로 인용되기를 희망하는 청구로서, 병합된 청구들 중 심리의 시작점이 된다. 주위적 청구가 인용되면 원고의 목적이 달성된 것으로 보아 후순위 청구에 대한 심리는 필요하지 않게 된다.

II. 예비적 청구의 정의

- 예비적 청구란 주위적 청구가 법원에서 기각되거나 각하될 경우를 대비하여 제2차적으로 심판을 구하는 청구를 의미한다. 즉, 주위적 청구가 받아들여지지 않았을 때 비로소 심리해 달라는 조건부 청구의 성격을 가진다. 이는 원고가 주위적 청구의 승소 가능성에 확신이 없을 때, 차선책으로서의 권리구제를 도모하기 위해 제기한다.

III. 예비적 병합의 성립 요건과 허용 범위

1. 청구 간의 양립 불가능성

- 예비적 병합은 원칙적으로 주위적 청구와 예비적 청구가 서로 양립할 수 없는 관계에 있을 때 제기한다. 예를 들어 계약이 유효함을 전제로 한 이행 청구(주위적)와 계약이 무효임을 전제로 한 원상회복청구(예비적)는 동시에 인용될 수 없으므로 예비적 병합의 전형적인 대상이 된다. 다만, 최근 판례와 학설은 양립 가능한 청구라 하더라도 원고가 순위를 붙여 병합할 의사가 명확하다면 이를 허용하는 경향이 있다.

2. 소송절차의 공통성

- 병합되는 여러 청구는 동일한 종류의 소송절차에 의하여 심리될 수 있어야 하며, 해당 법원에 그 청구들에 대한 관할권이 존재해야 한다. 행정소송법 제10조에 따른 관련 청구의 이송 및 병합 규정은 이러한 절차적 연계성을 보장하는 근거가 된다.

IV. 소송 절차에서의 심리 방식

1. 심리의 순서

- 법원은 원고가 붙인 순위에 구속된다. 따라서 반드시 주위적 청구를 먼저 심리하여야 하며, 주위적 청구가 인용될 수 있음에도 불구하고 이를 무시하고 예비적 청구를 먼저 인용하는 것은 허용되지 않는다. 만약 주위적 청구가 인용된다면 예비적 청구는 심리할 필요가 없는 부적정 조건이 되어 심판 대상에서 제외된다.

2. 주위적 청구 기각 시의 심리

- 법원이 주위적 청구를 심리한 결과 근거가 없다고 판단하여 기각하거나 소송요건 흠결로 각하하는 경우, 비로소 예비적 청구에 대한 심리를 시작한다. 이때 법원은 예비적 청구의 당부를 판단하여 인용 또는 기각 판결을 내리게 된다.

V. 판결의 형식과 효력

1. 전부인용 및 일부인용의 양태

- 주위적 청구가 인용되는 경우 법원은 주위적 청구에 대해서만 주문에 기재하며, 예비적 청구에 대해서는 별도의 판단을 내리지 않는다. 반면 주위적 청구가 기각되고 예비적 청구가 인용되는 경우에는 주문에 주위적 청구의 기각 사실과 예비적 청구의 인용 사실을 모두 기재하여야 한다.

2. 상소와의 관계

- 주위적 청구가 기각되고 예비적 청구가 인용된 판결에 대하여 피고가 항소한 경우, 상소의 불가분 원칙에 따라 주위적 청구 부분도 함께 상소심으로 이전된다. 항소심 법원은 다시 주위적 청구부터 심리하여야 하며, 만약 항소심에서 주위적 청구가 인용될 수 있다고 판단한다면 제1심 판결을 취소하고 주위적 청구 인용 판결을 내려야 한다.

VI. 행정쟁송에서의 특수성

1. 무효등 확인소송과 취소소송의 병합

- 행정소송에서 가장 빈번하게 나타나는 형태는 주위적으로 처분의 무효등 확인을 구하고, 예비적으로 처분의 취소를 구하는 병합이다. 하자의 정도가 중대명백하여 무효인지를 먼저 따져보고, 만약 무효가 아니라면 취소사유에 해당하는지를 판단해 달라는 취지이다. 판례는 이러한 형태의 병합을 예비적 병합의 전형으로 인정한다.

2. 제소기간 준수 여부

- 예비적으로 취소소송을 병합하는 경우, 주위적 청구인 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없으나 예비적 청구인 취소소송은 제소기간 내에 제기되어야 함이 원칙이다. 다만, 주위적 청구의 제기 시점이 취소소송의 제소기간 내였다면 병합된 예비적 청구 역시 적법한 것으로 간주된다.

VII. 관련 판례를 통한 검토

1. 심판 범위에 관한 판례

- 법원이 주위적 청구를 인용하면서 예비적 청구까지 판단한 경우, 이는 상소심에서 절차적 위법으로 지적될 수 있다. 판례는 주위적 청구가 인용되었음에도 예비적 청구를 판단하는 것은 원고의 의사에 반하며 소송 계속의 범위를 이탈한 것이라고 보고 있다.

2. 예비적 피고 추가의 문제

- 과거에는 청구의 병합뿐만 아니라 피고를 예비적으로 추가하는 것이 허용되지 않았으나, 현재 민사소송법 및 행정소송법 해석상 일정한 요건 하에 예비적 피고 추가가 인정되고 있다. 이는 누구에게 책임이 있는지 불분명한 상황에서 원고가 피고를 선택적으로 지정하여 소송을 제기할 수 있게 함으로써 권리 구제의 범위를 넓힌 것이다.

3. 판단유탈의 문제

- 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대해 판단을 누락한 경우, 이는 판단유탈에 해당하여 상소 사유가 된다. 법원은 원고가 제기한 순위에 따라 모든 청구에 대한 응답을 완료해야 할 의무가 있기 때문이다.

VIII. 결론

- 주위적 청구와 예비적 청구는 원고의 권리 구제를 극대화하기 위한 전략적 소송 형태이다. 주위적 청구는 원고가 지향하는 최우선의 법적 상태를 확정하는 도구이며, 예비적 청구는 법적 불확실성에 대비한 안전장치로서 기능한다. 이러한 병합 청구는 법원으로 하여금 사안의 실체를 다각도에서 검토하게 하여 분쟁의 일회적 해결을 가능케 한다. 실무적으로는 청구 간의 논리적 선후 관계를 명확히 설정하고 각 청구의 요건을 개별적으로 입증하는 태도가 요구된다. 특히 행정소송에서는 하자의 정도에 따른 소송 형태의 병합이 빈번하므로, 무효와 취소의 법리를 주위적·예비적 구조 내에서 조화롭게 배치하는 것이 실효적인 권리 구제의 핵심이 된다.